



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000802280

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000177-09.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso da impetrante, v. u.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO NOTARANGELI (Presidente) e OSWALDO LUIZ PALU.

São Paulo, 20 de outubro de 2017.

Rebouças de Carvalho

Relator

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 24065-jv

APELAÇÃO Nº 0000177-09.2017.8.26.0053

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO

IMPETRADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que almeja a expedição de Declaração de Potencial Construtivo Transferível de imóvel, com alteração da classificação da categoria de zoneamento – Descabimento - Imóvel com tombamento em curso (Tombamento Provisório), situado em bairro tombado (Pacaembu e Perdizes) (SC 08/91/CONDEPHAAT) – Tombamento Provisório que se equipara ao Definitivo (art. 10, par. Único, do Decreto-Lei nº 25/37) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do C. STJ – Lei Municipal nº 16.050/14, que dispõe expressamente ser impossível a transferência de potencial construtivo originário de bairros tombados (art. 124, par. 2º) – Denegação da segurança mantida – Recurso da impetrante não provido.

Mandado de segurança impetrado em favor da Fundação Armando Alvares Penteado contra ato praticado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano na Cidade de São Paulo, consistente no indeferimento da expedição de Declaração de Potencial Construtivo Transferível.

Segundo afirma a impetrante, o imóvel deve ser classificado como categoria ZEPC-DIR, a fim de conferir-lhe o direito a expedição da Declaração pretendida, possibilitando o potencial construtivo básico, ainda que o imóvel se encontre em processo de tombamento provisório.

Indeferida a liminar (fl. 40).

A r. sentença de fls. 110/116, cujo relatório se adota,

denegou a segurança, por entender inexistente autorização legal que possibilite ao imóvel em processo de tombamento não finalizado obter Declaração de Potencial Construtivo Transferível.

Inconformada, apela a impetrante, a fls. 119/128. Sustenta que o processo de tombamento do imóvel em questão não produz objeção ao potencial construtivo deste bem, além de observar a preservação da condição do bem tombado, sendo até admitido a reversão do tombamento.

Recurso recebido, processado, e contrariado (fls. 133/150).

É o relatório.

O caso é de manutenção da r. sentença.

De fato, está inequívoco nos autos que o imóvel da Rua Alagoas (SQL 011.086.0009-3) se encontra desde 2005, sob condição de tombamento, conforme se infere da Resolução nº 50.806/05, do CONDEPHAAT (fls. 36), e que a impetrante objetiva a expedição de Declaração de Potencial Construtivo Transferível em relação a este imóvel

Conquanto a proprietária exerça seu amplo direito sobre o imóvel, não se deve ignorar que há legítima competência do ente público em impor limitações administrativas ao bem, a fim de que prevaleça o interesse público na preservação do patrimônio histórico, arquitetônico, Artístico e Turístico.

Neste Assevera HELY LOPES MEIRELLES o seguinte:

“As limitações administrativas ao uso da propriedade particular podem ser expressas em lei ou regulamento de qualquer das três entidades estatais, por se tratar de matéria de Direito Público (e não de Direito Civil, privativo da União), da competência concorrente federal, estadual e municipal. O

essencial é que cada entidade, no impor a limitação, mantenha-se no campo de suas atribuições institucionais” (Direito Administrativo Brasileiro”, 37ª edição, 2011, Malheiros Editores p. 682).

Nestas limitações administrativas estão a imposição de zoneamento, com vistas a preservação do bem que o ato de tombamento lhe impôs, a proteger o conjunto urbanístico e edifício de determinado imóvel, não havendo como transferi-lo para outra localidade.

Como sabido, conforme conceitua HELLY LOPES MEIRELLES, *“O tombamento é ato administrativo que preserva o bem de modificação e destruição, mas não veda sua normal utilização pelo proprietário, nem lhe retira o domínio e a posse.”* (Direito Municipal Brasileiro”, Editores Malheiros, 15.ª ed., p. 563/566).

Conforme anotado nas informações da Prefeitura Municipal de São Paulo o imóvel “não foi classificado na categoria DIR, mas AUE (Área de Urbanização Específica)”, em razão do “tombamento dos Bairros do Pacaembu e Perdizes pela Resolução SC 08/91/CONDEPHAAT, não preenchendo o requisito legal para transferência do direito de construir” (fls. 74).

Frisa-se ainda que, mesmo reputando provisório o tombamento do imóvel, não se ignora que o art. 10, par. Único, do Decreto-Lei nº25/37, deixa expresso que “o tombamento provisória se equipará ao definitivo”.

Há precedente deste E. Tribunal de Justiça neste sentido:

APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO URBANÍSTICO - ATO ADMINISTRATIVO EMBARGO DE OBRA REALIZADA EM IMÓVEL OBJETO DE TOMBAMENTO PROVISÓRIO Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento da invalidade de procedimento de tombamento provisório realizado pelo CONDEPHAAT (Conselho de

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), referente à área em que situado o imóvel do impetrante cabimento desnecessidade de intimação pessoal do proprietário de imóvel situado em área de tombamento geral, sendo suficiente, para tanto, a notificação dos entes da Administração Pública em que se dará a limitação, a fim de que esta zele pela adequada proteção ao patrimônio cultural, evitando, assim, situações de abuso de direito situação dos autos, ademais, em que o impetrante obteve acesso ao procedimento administrativo e pôde exercer suas garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/88) o tombamento, ainda que provisório, gera grave limitação ao direito de propriedade e, por isso, deve guardar estrito respeito ao rocedimento (forma e prazos) previsto em lei, sob pena de se configurar ato ilegal excesso de prazo configurado - caducidade do direito potestativo da Administração no processo de conversão do tombamento provisório em definitivo - sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recurso voluntário da Fazenda Estadual e oficial do Juízo “a quo” improvidos. (apel. nº 1003892-47.2014.8.26.0053, Des. PAULO BARCELLOS GATTI, j. 20/10/2014).

Neste mesmo sentido é o que decide o STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO PROVISÓRIO. EQUIPARAÇÃO AO DEFINITIVO. EFICÁCIA.

1. O ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivo, tem por finalidade preservar o bem identificado como de valor cultural, contrapondo-se, inclusive, aos interesses da propriedade privada,

não só limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas também obrigando o proprietário às medidas necessárias à sua conservação. O tombamento provisório, portanto, possui caráter preventivo e assemelha-se ao definitivo quanto às limitações incidentes sobre a utilização do bem tutelado, nos termos do parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei nº 25/37. 2. O valor cultural pertencente ao bem é anterior ao próprio tombamento. A diferença é que, não existindo qualquer ato do Poder Público formalizando a necessidade de protegê-lo, descaberia responsabilizar o particular pela não conservação do patrimônio. O tombamento provisório, portanto, serve justamente como um reconhecimento público da valoração inerente ao bem. 3. As coisas tombadas não poderão, nos termos do art. 17 do Decreto-Lei nº 25/37, ser destruídas, demolidas ou mutiladas. O descumprimento do aludido preceito legal enseja, via de regra, o dever de restituir a coisa ao status quo ante. Excepcionalmente, sendo manifestamente inviável o restabelecimento do bem ao seu formato original, autoriza-se a conversão da obrigação em perdas e

danos. (REsp nº 753.534-MT, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 25/10/2011)

Desta sorte, o imóvel em questão está a suportar limitações administrativas que visam garantir o patrimônio cultural, Artístico, e histórico da Cidade, em perfeita harmonia com a previsão constitucional do art. 216, V, da CF¹

¹ Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Portanto, a reforma, demolição ou qualquer outra iniciativa para descaracterização do bem tombado ou em processo de tombamento (fls. (fl. 36), notadamente a alteração administrativa de seu zoneamento, exigiria expressa previsão Legal, o que não há no caso concreto, ao contrário, o art. 1º, do Decreto-Lei nº 25/37, define que “Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”.

Enfim, a legislação que aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico no Município de São Paulo, Lei Municipal nº 16.050/14, não deixa a menor dúvida de que os imóveis tombados enquadram-se na categoria ZEPEC (art. 61, par. Único)².

A par desta caracterização legal da categoria do imóvel da impetrante em ZEPEC, o art. 124, pr. 2º, da Lei Municipal nº 16.050/14, dispõe que “Não poderão ser realizadas transferências de potencial construtivo originário de bairros tombados em Área de Urbanização Especial (AUE) e das Áreas de Proteção Paisagística (APPa).

Assim, por haver o tombamento do Bairro do Pacaembu e Perdizes, com classificação da categoria que AUE – Área de Urbanização Específica (fl. 74), é de se admitir como legítimo o indeferimento da expedição de Declaração de Potencial Construtivo Transferível.

Enfim, não há como o Poder Judiciário anular legítima decisão administrativa, fundamentada em legislação de regência, nem proceder a cancelamento de processo de tombamento em curso (fl. 36), ainda que provisório, sem a possibilidade de alterar a classificação da categoria do zoneamento do imóvel em processo de tombamento, razão pela qual cabível a manutenção da denegação da segurança.

² **Art. 61, Parágrafo único.** Os imóveis ou áreas tombadas ou protegidas por legislação Municipal, Estadual ou Federal enquadram-se como ZEPEC.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da impetrante.

REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator